

1523276-49.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cynthia Torres Cristofaro

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Réu:

DIEGO GAMARRA RODRIGUES e ALEX NASCIMENTO VIEIRA

Juíza de Direito: Dra. Cynthia Torres Cristófaru

Vistos.

DIEGO GAMARRA RODRIGUES e ALEX NASCIMENTO VIEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, na forma do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1523276-49.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1523276-49.2021.8.26.0228 - 2021/001201

Autora:

Justiça Pública

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Réu:

DIEGO GAMARRA RODRIGUES e ALEX NASCIMENTO VIEIRA

Juíza de Direito: Dra. Cynthia Torres Cristófaru

Vistos.

DIEGO GAMARRA RODRIGUES e ALEX NASCIMENTO VIEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, na forma do artigo 29 do Código Penal, porque teriam, no dia 24 de setembro de 2021, por volta de 16h45min, na Alameda Dino Bueno, 28, Santa Cecília, nesta cidade e Comarca, previamente ajustados e em identidade de designios, trazido consigo e transportado, para entrega a consumo de terceiros, 3 porções com 57,9 gramas de crack, substância determinante de dependência física e psíquica, sem

autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Os réus foram presos em flagrante delito, tendo sido a prisão em flagrante de Diego convertida em preventiva, concedida liberdade provisória a Alex (fls. 67/71).

Os acusados foram regularmente citados e notificados (fls. 141 e 143), e apresentaram defesa preliminar por meio da Defensoria Pública (fls. 146/147), recebida a denúncia (fls. 149) e renovada a citação.

Durante a instrução, tomaram-se os depoimentos de duas testemunhas, tendo sido os réus interrogados.

Manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação do acusado, nos termos da denúncia; pleiteou a defesa a absolvição, por falta de provas, pretendendo subsidiariamente a desclassificação ao delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006 ou a fixação de penas no mínimo, atenuadas por menoridade relativa / por confissão / compensada reincidência por confissão, com máxima redução, em regime brando tomada detração, com substituição, sendo facultado recurso em liberdade.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória comporta integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado, clara a tipicidade, não havendo dúvidas quanto à autoria, correta a classificação dada à conduta.

O réu Alex, ouvido na delegacia, disse que é usuário de entorpecentes e iria entregar a droga apreendida a outra pessoa, dentro do fluxo da cracolândia (fls. 8); ouvido em Juízo, informou que é usuário de drogas e de álcool, estava havia dias sem dormir, estava ficando na cracolândia; ia passando no movimento depois da limpeza; um sujeito conhecido de vista vinha arrastando umas coisas pesadas, pediu que ajudassem a carregar, dizendo que ia dar uma pedrinha de crack; estava meio fora de si, já sem droga para consumir; o sujeito passou e se misturou com a multidão, quando foram passar com as coisas que ele pediu para carregar, foram parados pelos guardas, que encontraram no meio as drogas, que não sabia que estavam ali no meio; não conhecia os guardas anteriormente; negou antecedentes.

O réu Diego, ouvido na delegacia, disse que é usuário de entorpecentes e iria entregar a droga apreendida a outra pessoa, dentro do fluxo da cracolândia (fls. 9); ouvido em Juízo, disse que é usuário de crack, estava na cracolândia havia uns 4 meses; não conhecia Alex, mas estavam próximos; na hora da limpeza, uma pessoa que conhecia de vista ofereceu uma pedrinha de crack para cada um para que puxassem a manta dele que estava com um monte de coisa dentro, acredita que a pessoa tenha colocado a sacola com drogas no meio de suas coisas por má fé; ele passou e entrou no meio da multidão, enquanto foram parados pelos guardas, que encontraram as drogas; não conhecia os guardas anteriormente, teve condenação anterior por tráfico.

As negativas apresentadas pelos acusados vêm isoladas nos autos, confrontadas pelo mais da prova colhida, a qual demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

As circunstâncias da prisão e da apreensão foram descritas com clareza pelos guardas municipais ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então os acusados, apresentaram relatos detalhados e convincentes, coincidentes entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido.

Os guardas municipais Rinaldo e Wilton relataram em Juízo que na movimentação que ocorre na limpeza pública na cracolândia, os réus vinham puxando umas cobertas velhas; mandaram que parassem, um deles correu e o outro ficou, ambos foram abordados; no meio das cobertas, havia vários itens, como roupas sujas e sapatos e, no meio disso, duas ou três pedras de crack grandes e cerca de 900 reais em dinheiro; os réus disseram que estavam passando a droga pela revista para o traficante a troco de crack para seu consumo; ambos aparentavam ser usuários de crack; esse tipo de ocorrência é bem comum no local, os traficantes que ficam no meio dos usuários realmente se utilizam de usuários para passar as drogas nesses momentos de limpeza e revista a troca de pedrinhas de crack.

Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os guardas municipais

alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, inclusive no tocante à confissão informal a eles prestada por ocasião da abordagem, convindo notar que os réus não eram conhecidos anteriormente dos guardas e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa.

Bem assentado, assim, que os réus foram realmente surpreendidos quando passavam entre dois locais por ocasião da limpeza realizada na cracolândia as porções de crack e o dinheiro nitidamente angariado com a atividade ilícita.

Os réus vinham transportando entorpecente destinado ao tráfico em estado de flagrância, consistindo sua conduta justamente em propiciar a passagem da droga a local de concentração de usuários burlando fiscalização estatal que era realizada pela guarda municipal no cumprimento de missão de patrulhamento preventivo destinado a coibir infrações penais contra bens, serviços e instalações municipais, de conformidade com o previsto pela Lei 13.022/2014, artigos 3º e 5º.

Naturalmente que dando a guarda municipal, no desempenho dessas atribuições, com a prática de crime em estado de flagrância, é legitimada, tanto quanto é qualquer do povo, a realizar a prisão em flagrante, convindo notar que no caso em exame a intervenção dos guardas deu-se em razão de fundada suspeita que a conduta dos acusados motivou, e que se mostrou efetivamente acertada.

Não há demonstração do alegado erro. Não havia razão plausível para que outro usuário de drogas se dispusesse a presentear os réus com porções de crack para que passassem suas coisas pela fiscalização a não ser a presença da droga no meio dos pertences, coisa que aos réus não era dado desconhecer, não se mostrando plausíveis suas alegações.

O conjunto probatório é seguro e convincente, dado que é pelos relatos coincidentes das testemunhas, de tal sorte que materialidade e autoria do delito encontram-se perfeitamente comprovadas.

As drogas vêm descritas no auto de apreensão de fls. 13, estando a materialidade do delito demonstrada pelo auto de constatação de fls. 18/20 e pelo laudo químico toxicológico de fls. 156/158, em que apontada a presença do princípio ativo característico na substância apreendida.

A quantidade, a espécie, o modo de disposição das drogas e as circunstâncias em que apreendidas não se mostram compatíveis com destinação outra que não o comércio ilícito, de que claramente proveniente o dinheiro apreendido.

A conduta é típica e, não obstante a situação realmente desastrosa em que se encontravam os réus, reclama intervenção estatal, cuja ausência acabaria redundando em aumento do ilícito pela forma aqui apurada.

A condenação dos acusados é, pois, de rigor. Passo à dosagem das penas que lhe serão impostas.

Ao delito descrito pelo caput do artigo 33 da Lei 11.343/06 são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, as quais, consideradas exclusivamente para fixação da base, não se mostram de todo desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Atenuantes genéricas não incidem, dado não terem o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, em observância ao princípio da legalidade (Súmula STJ 231). Embora o réu Diego seja reincidente, como comprova a certidão de fls. 46/48, uma vez que tal circunstância atuará adiante para obstar a diminuição da pena na forma do parágrafo 4º ao artigo 33, não se presta a caracterizar a agravante genérica prevista pelo artigo 61, inciso I, do Código Penal, desde que assim não fosse ocorreria bis in idem.

Não incide a causa de diminuição prevista pelo parágrafo 4º ao artigo 33, dada a reincidência do acusado Diego, de sorte que torno definitivas as penas fixadas.

A causa de diminuição prevista pelo parágrafo 4º incide em grau médio de 3/5 para o réu Alex frente a sua primariedade, demonstrada pela FA de fls. 49/52, e à ausência de notícia de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosas. Não houve, entretanto, demonstração de aptidão a vida regrada ou de dedicação a vínculo duradouro de trabalho, não tendo o réu comprovado registro de

emprego ainda que pretérito em carteira de trabalho ou mesmo apresentado declaração de emprego, ausente prova positiva, que cabia à defesa, de bons antecedentes (os quais não se inferem da mera ausência de maus antecedentes). Vão as penas, pois, a 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, em definitivo, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo para o réu Diego o regime fechado, único que se mostra adequado à consecução das finalidades da sanção penal, mesmo à vista do quantum fixado, considerada a gravidade objetiva da conduta em exame, que reclama reação severa, proporcional e seguramente eficaz, atendida a reincidência. Para o réu Alex, primário, fixo o regime aberto, adequado a suas circunstâncias pessoais.

Nesse ponto anoto que o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante (TJSP, 13ª Câ. Crim., Habeas Corpus nº 0190234-85.2013.8.26.000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 16/01/2014).

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

Ausentes os requisitos legais, inviável a substituição da pena corporal. Apesar de suspensão vedação legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pela Resolução 5/2.012 do Senado Federal, a natureza do delito não se coaduna com a benesse pretendida, cuja aplicação redundaria em comprometimento da finalidade da sanção penal, em especial no tocante à função de prevenção geral, não se afigurando a medida socialmente recomendável (art. 44, inciso III, e § 3º, CP).

A suspensão condicional da pena, contudo, passível de revogação com obrigação de integral cumprimento da pena corporal é admissível a Alex, acenando com mais relevante consequência, melhor atendendo ao reclamo de proporcionalidade da pena. Determino, pois, a suspensão da execução da pena privativa de liberdade imposta a Alex pelo período de dois anos, ao longo do qual obrigado o condenado a comparecer mensalmente perante o Juízo de Execução para informar e justificar suas atividades, ficando proibido de mudar de endereço e de se ausentar da comarca de residência sem prévia autorização judicial; no primeiro ano do período de prova, o réu está obrigado a participar de qualquer medida de tratamento (psicoterapia, acompanhamento via CAPES, reunião dos Narcóticos Anônimos, etc).

À mingua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas dos acusados, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar:

- a) o réu DIEGO GAMARRA RODRIGUES, qualificado a fls. 15, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo;
- b) o réu ALEX NASCIMENTO VIEIRA, identificado a fls. 14, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, às penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, no valor unitário mínimo. Suspendo a execução da pena de reclusão pelo prazo de 2 (dois) anos, ao longo do qual obrigado o réu a comparecer mensalmente perante o Juízo de execução para informar e justificar suas atividades e proibido de mudar de endereço e de se ausentar da Comarca de residência sem prévia autorização judicial; no primeiro ano do período de prova, o réu está obrigado a participar de qualquer medida de tratamento (psicoterapia, acompanhamento via CAPES, reunião dos Narcóticos Anônimos, etc).

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar do acusado Diego no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, patente o risco de que solto procure

obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu Diego na prisão em que se encontra. Autorizo que se proceda à destruição das drogas apreendidas. Oficie-se desde logo para tanto.

Após o trânsito em julgado a) elaborem-se cálculos de multa e intimem-se os réus para o pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeçam-se e encaminhem-se cartas de guia / aditamentos; c) proceda-se à transferência do dinheiro apreendido a fls. 13 e depositado a fls. 104 ao Funad, decretado seu perdimento em favor da União; d) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, intimadas as partes. Comunique-se.

São Paulo, 07 de fevereiro de 2022.

VAI ESTE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, CONFORME É APONTADO EM SUA MARGEM SUPERIOR / DIREITA